

1500043-90.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... provas suficientes da prática do tráfico. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, e aumento da pena de forma módica em razão de sua reincidência.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Kristiano Soares Botta, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500043-90.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500043-90.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007096/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 22341576 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

152/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2007096 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

152/22/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kristiano Soares Botta

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Kristiano Soares Botta, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 75/76.

O réu foi preso em flagrante no dia 08 de janeiro de 2022. A decisão de fls. 47/50, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Oferecida a denúncia, o réu foi devidamente notificado nos termos do artigo 55, da Lei n. 11.343/06 (fls. 90), e apresentou defesa preliminar de fls. 94/95, por meio

de seu Defensor constituído.

A denúncia foi recebida no dia 25 de março de 2022, conforme decisão de fls. 100/106, que ainda designou audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa, e interrogado o réu.

Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia. O d. Defensor, também em alegações orais, requer, a título de preliminar, o reconhecimento da existência de nulidade do processo, a partir da prisão em flagrante, visto que o ato foi realizado por Guardas Municipais, que não teriam atribuição para a realização de policiamento preventiva e ostensivo, nos termos do artigo 144 da CF/88. No mérito, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, visto que o réu é apenas usuário de drogas, e na data dos fatos foi surpreendido na posse de algumas porções que havia adquirido no local para seu próprio consumo, não havendo provas suficientes da prática do tráfico. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, e aumento da pena de forma módica em razão de sua reincidência.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Kristiano Soares Botta, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta de 17h25min, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina nas imediações da Avenida 30, altura do número 261, bairro Jardim Brasília, nesta cidade de Rio Claro, local já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o réu agachado em meio a uma matagal que lá existe. Tal conduta chamou a atenção dos guardas, ainda mais porque o réu foi visto, em seguida, mantendo contato com o ocupante de um veículo, que conseguiu se evadir. O réu foi abordado, e durante revista pessoal, os guardas encontraram em seu poder 06 porções de cocaína, e 03 porções de maconha. Por fim, com o apoio de um cão farejador, novas buscas foram realizada no mesmo local onde o réu fora visto agachado, onde foram encontradas mais 18 porções de cocaína, e 22 porções de maconha.

Encerrada a instrução, temos que a ação penal é procedente.

De início, afasta-se a alegação de que a prisão em flagrante do réu seria nula, pois realizada por guardas municipais, no exercício de seus funções.

De início, temos que o acusado foi abordado diante das fundadas suspeitas da prática de ilícito, e não por mero capricho ou subjetivismos dos guardas municipais. Segundo o que consta, o acusado encontrava-se em local onde é alta a incidência do tráfico de drogas, e inicialmente estava agachado no meio de um matagal. Em seguida, dirigiu-se até um veículo, onde fez gestos de que entrega e/ou recebia algo do motorista, o que certamente justificava sua abordagem diante das características do local.

Ademais, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela:

“Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.”

Outrossim, a alegação de ilicitude do ato perpetrado pelos guardas municipais pelo fato de supostamente terem abordado o réu em atos de policiamento ostensivo não tem o condão de desnaturar a validade das diligências efetuadas, diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e, conseqüentemente, da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes públicos municipais, em conformidade com o que preconiza o artigo 302 e 303, ambos do Código Penal:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 303. Nas infrações permanentes, entendese o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência."

E este é o entendimento desta do Eg. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas. Preliminar afastada. Prisão em flagrante efetuada por guardas municipais. Provas ilícitas. Inocorrência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Decisão condenatória que se impõe. Penas readequadas. Afastado o aumento da pena-base - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo, da Lei de Drogas, em razão da quantidade de entorpecente apreendido. Precedentes STJ e 15ª Câmara Criminal. Regime inicial fechado devido Recurso Provido em parte." (APL 0009078-38.2017.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Ricardo Sales Junior, j. 13/12/2018).

Nesse rumo, ainda, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal Justiça: 'Prisão em flagrante Guarda municipal. Apreensão de coisas. Legalidade. Delito permanente "A guarda municipal, a teor do disposto no parágrafo 8º do art. 144, da CF, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio da auto-defesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta também a apreensão de coisas, objeto do crime. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial" (STJ Rel. Fernando Gonçalves RJ 255/127).

"HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI N.º 11.343/06. TESE DE INOCÊNCIA. REEXAME DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante delito na posse de 01 (uma) porção de "maconha" e 04 (quatro) porções de "haxixe", tendo sido encontrados, ainda, em sua residência, "cocaína", uma balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico. 2. Não procede a arguida irregularidade da prisão do Paciente, por ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, pois, sendo o tráfico ilícito de drogas delito permanente, pode a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. Precedente. 3. É firme a orientação da Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação expressa da liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, por si só, motivo suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto no art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição da República, que impõe a inafiançabilidade das referidas infrações penais. Precedentes desta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, as instâncias ordinárias reconheceram a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal na hipótese em apreço, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida. 5. A apreciação da tese de inocência do Paciente demanda, inevitavelmente, o reexame da matéria fático-probatória, o qual, como é sabido, não se coaduna com a via estreita do writ. 6. Ordem denegada." (STJ 5ª Turma, Habeas Corpus nº 222.173/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011, DJe 01/12/2011).

No mérito, temos que a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de fls. 16, que atesta a apreensão das porções de cocaína e de maconha. Parte da droga estava em poder do réu, e parte no meio do matagal onde foi visto agachado. O laudo de fls. 82/84, por sua vez, apresentou resultados positivos para maconha e cocaína.

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos, mas apenas em parte. Alegou que é usuário de drogas há 15 anos, e que na data em questão foi até o ponto de tráfico existente na Avenida 30, bairro Jardim Brasília. Lá chegando, manteve contato com um indivíduo que se encontrava agachado no meio do referido matagal, de quem

adquiriu 06 porções de cocaína, e 03 porções de maconha. Em seguida, quando já deixava o local, foi abordado pelo motorista de uma van, que lhe perguntou quem vendia droga não local naquele dia. O réu então indicou a direção onde se encontrava o traficante, mas logo em seguida foi abordado pelos guardas municipais. Negou, portanto, que a droga encontrada no meio do mato fosse sua, ou mesmo que estivesse praticando o tráfico. Negou ter confessado os fatos perante a Autoridade Policial, e disse ter assinado vários papéis na Delegacia de Polícia, desconhecendo o seu teor.

Contudo, a versão apresentada pelo réu não encontra amparo no restante da prova. De início, temos que o réu, quando na presença da Autoridade Policial, confessou os fatos de maneira direta e singela. Alegou que havia saído da cadeia no mês de setembro de 2021, e que tinha dívidas a saldar com o tráfico de drogas, no valor de três mil reais. Para pagar o que devia a traficantes, pôs-se a vender a drogas. Admitiu que traficava no dia dos fatos, e que a droga apreendida em seu poder teria tal finalidade. Negou apenas a posse da droga encontrada no meio do matagal (fls. 07).

A confissão extrajudicial, ainda mais porque nada sugere que tenha sido forjada, encontra amparo no restante da prova, e pode servir como importante indício para a condenação.

Nesse sentido:

“É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil.” (TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

Os guardas municipais Leandro e Dhieimison, ouvidos em juízo, de forma uníssona, declararam que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina pela Estrada dos Costas. Ao passarem no cruzamento com a Avenida 30, onde é corrente a prática do tráfico, chamou-lhes a atenção o acusado, que se encontrava agachado e mexendo em algo dentro de um matagal. O réu, naquele momento, não percebeu a passagem da viatura, que por sua vez deu meia volta, e ingressou na Avenida 30. Nesta momento, depararam-se com o réu entregando algo ao motorista de uma van de cor escura, em típica conduta de quem pratica o tráfico, ainda mais considerando as características do local. O motorista da van conseguiu fugir, de modo que apenas o acusado foi abordado, sendo encontradas em seu poder 06 microtubos contendo cocaína, e 03 porções de maconha. Em seguida, com a ajuda de um cão farejador, os guardas realizaram buscas no meio do matagal, e no mesmo ponto o réu havia sido visto agachado, encontraram o restante da droga.

Ou seja, o réu foi flagrante pelos guardas no exato momento em que vendia drogas ao ocupante da van, cuja presença no local foi confirmada pelo próprio acusado, quando ouvido em juízo. Nada há nos autos indicando que os guardas teriam confundido o réu com o verdadeiro traficante, ou mesmo que Kristiano tenha ido até aquele ponto apenas para comprar drogas. O réu foi visto mexendo no matagal onde foram encontradas várias porções de cocaína e maconha, e em seguida entregando algo ao motorista de uma van, não restando dúvidas de que estava no local praticando o tráfico, tal como admitiu quando da primeira vez em que foi ouvido nos autos. Como é cediço, as palavras dos agentes policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário não produzida nestes autos, estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida, e amparada pela confissão extrajudicial.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de,

precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez”(RJTJESP 136/477).

Portanto, restou sobejamente demonstrado que o acusado foi abordado por guardas municipais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, e no momento em que entregava algo ao motorista de uma van. Abordado, foram encontradas 06 porções de cocaína, e 03 porções de maconha em seu poder. Em seguida, onde foi visto inicialmente, foram apreendidas outras 18 porções de cocaína, e 22 porções de maconha. A abordagem policial, portanto, se mostrou devidamente motivada, de modo que não padece de nulidade alguma, até mesmo porque evidenciada a situação de flagrante delito. Neste sentido o entendimento do E. TJSP:

“APELAÇÃO tráfico de drogas. Suficiência probatória. Apelo do MP. Alteração do decreto absolutório. Falta de segurança quanto a prova colhida afastada. Observação pelos Policiais Militares, durante algum tempo, que afirmaram ter visto movimentação do apelado e dois menores inimputáveis. Abordagem de pessoa que por ali passando teve contato desse tipo com o trio e que estando com drogas, disse daquele local como o de aquisição. Ainda que dita pessoa pretenda não reconhecer o apelado, como é comum entre usuários e para não perder benesse futura de fornecedor, não só a visualização demonstrou essa situação, como afastou que se pudesse considerar ocorrência de passagem aleatória do apelado por ali continuidade, sequência plano na observação que dá certeza da presença contínua dele ali. Prova de defesa que não afasta essa convicção. Ação policial: observação à distância, visualização do movimento, dando segurança e apoio à ação de abordagem do apelado e menores. Certeza de prática do delito de tráfico confirmada, inclusive pelo encontro de droga no local para onde havia direcionamento de ação com a chegada de usuários adquirentes. Não infração visualizada, considerada, de violação a direitos. Na fase do art. 59, CP, fixação da pena no mínimo legal. Acréscimo mínimo pela forma do concurso de menores e proximidade de lugar público. Redução pela aplicação do redutor. Regime prisional fechado inicial. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP, 3ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal1500277-79.2019.8.26.0614, Relator Desembargador Ruy Alberto LemeCavalheiro; Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento:31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021).

A condenação, portanto, é medida de rigor.

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, e o artigo 42 do Código Penal. O réu é reincidente específico na prática do tráfico, conforme certidão de fls. 30/32 (autos n. 1500245-38.2020).

Contudo, nesta primeira fase, para evitar o bis in idem, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias multa, diária no mínimo legal. A quantidade de droga apreendida, não justifica a majoração da pena.

Na segunda fase, repita-se, temos ser o réu reincidente específico. Contudo, tendo ele confessado o delito na fase policial, e sendo tal elemento de prova considerado como relevante para fins de sua condenação, entendo que o aumento decorrente da reincidência resta anulado pela incidência da referida atenuante.

A reincidência impede a incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, e ainda justifica a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Nesse sentido:

“STF-0097479) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 33, § 2º, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II - A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III - A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP. III. Recurso Ordinário

em Habeas Corpus improvido. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 134829/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 28.03.2017, unânime, DJe 06.04.2017). Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para ao fim de condenar KRISTIANO SOARES BOTTA à pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, valendo observar que o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória pela prática de crime assemelhado a hediondo, ainda mais em se tratando de agente reincidente.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

“Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual”. (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar” (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U).  
Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA